

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0007774-29.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JOUBERT SANTOS MACHADO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Rafael Henrique Janela Tamai Rocha**

Vistos, etc...

JOUBERT SANTOS MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no **artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de setembro de 2017, por volta de 13h52, na Rua Lício de Miranda, altura do nº 276, bairro do Ipiranga, nesta cidade e comarca, o acusado tinha em depósito, trazia consigo, guardava, transportava e ocultava, para fins de mercancia, **89 (oitenta e nove) eppendorfs contendo cocaína, sob a forma de pó**, substância, esta, de uso proscrito no Brasil, consoante disposto na Lista F1 da Portaria nº 344/98, do Ministério da Saúde, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado no bojo do inquérito policial instaurado, por ocasião dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, em conhecido ponto de tráfico de drogas, oportunidade em que avistaram o acusado em atitude suspeita, na posse de uma sacola de cor verde. Este, ao pressentir a iminência da abordagem policial, tentou se evadir, sendo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

perseguido e detido.

Em meio a busca pessoal, houve a localização, em posse do acusado, mais especificamente no interior da sacola que carregava, dos 89 *ependorfs* de cocaína.

Inquirido informalmente, teria o acusado confessado a prática do tráfico de drogas, asseverando que adquirira cada *ependort* por R\$ 10,00, de modo a revende-lo por R\$ 20,00.

Ao ser Interrogado perante a autoridade policial, porém, o acusado reservou-se no direito constitucional ao silêncio.

O acusado foi preso em flagrante, tendo sido sua prisão regularmente convertida em prisão preventiva pelo Juízo responsável pelo Plantão Judiciário.

Posteriormente, acabou o acusado agraciado pelo benefício da Liberdade Provisória clausulada, após decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo a ser colocado em liberdade.

Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação do acusado (fls. 110) para a oferta de defesa prévia e resposta escrita, o que ocorreu a fls. 117/119. Após, foi a denúncia regularmente recebida (fls. 120).

Nesta data, foi realizada a audiência de instrução, com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, bem como foi o acusado interrogado.

Após, as partes ofertaram alegações finais orais,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

advindo a presente sentença.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De antemão, sobre o **ônus da prova**, entendo oportuna a ponderação de algumas ressalvas que balizarão a conclusão alcançada nesta sentença, ajustando sua distribuição, no âmbito penal, em conformidade com o filtro constitucional.

E, para tanto, soa adequado rememorar, com espeque na lição de **Aury Lopes Júnior**, que não se incumbem às partes obrigações, mas sim cargas processuais, *“entendidas como a realização de atos com a finalidade de prevenir um prejuízo processual e, conseqüentemente, uma sentença desfavorável. Tais atos se traduzem, essencialmente, na prova de suas afirmações”* (Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, pag. 45).

Ocorre que, no processo penal, a carga da prova está inteiramente nas mãos do acusador, *“não só porque a primeira afirmação é feita por ele na peça acusatória (denúncia ou queixa), mas também porque o réu está protegido pela presunção de inocência”* (ob. cit.) (Grifei).

Vale dizer, em âmbito penal, considerando a relevância e indisponibilidade da natureza da matéria discutida – liberdade do indivíduo – não existe uma *distribuição* na produção da prova, pois esta se encontra exclusivamente nas mãos do Ministério Público.

Ainda segundo o escólio do referido professor, “o que


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sim podemos conceber, indo além da noção inicial de situação jurídica, é uma assunção de riscos. Significa dizer que à luz da epistemologia da incerteza que marca a atividade processual e o fato de a sentença ser um ato de crença, de fé (como explicaremos a seu tempo), a não produção de elementos de convicção para o julgamento favorável ao seu interesse faz com que o réu acabe potencializando o risco de uma sentença desfavorável. Não há uma carga para a defesa, mas sim um risco. Logo, coexistem as noções de carga para o acusador e risco para a defesa.” (Grifo no original) (ob. cit.).

Em outras palavras, “carga é um conceito vinculado à noção de unilateralidade, logo, não passível de distribuição, mas sim de atribuição. No processo penal, a atribuição da carga probatória está nas mãos do acusador, não havendo carga para a defesa e tampouco possibilidade de o juiz auxiliar o MP a liberar-se dela (recusa ao ativismo judicial)” (ob. cit.).

Pode-se falar, portanto, que a defesa assume riscos pela perda de uma chance. “Assim, quando facultado ao réu fazer prova de determinado fato por ele alegado e não há o aproveitamento dessa chance, assume a defesa o risco inerente à perda de uma chance, logo, assunção do risco de uma sentença desfavorável. Exemplo típico é o exercício do direito de silêncio, calcado no nemo tenetur se detegere. Não gera um prejuízo processual, pois não existe uma carga. Contudo, potencializa o risco de uma sentença condenatória. Isso é inegável” (ob. cit.) (Grifei).

A conclusão a que se alcança, portanto, é a de que “não há uma carga para a defesa exatamente porque não se lhe atribui um prejuízo imediato e tampouco possui ela um dever de liberação. A questão desloca-se para a dimensão da assunção do risco pela perda de uma chance de obter a captura psíquica do juiz. O réu que cala assume o risco decorrente da perda da chance de obter o convencimento do juiz da veracidade” (ob. cit.)

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(Grifei).

Em suma, a necessidade de produção da prova para amparar a condenação do réu repousa unicamente nas mãos da acusação, não havendo que se falar em distribuição de *cargas processuais*.

Assentadas essas premissas, passo ao crime perquirido.

A **pretensão punitiva estatal** deve ser julgada **parcialmente procedente**, com a condenação da acusada pela prática do **crime de porte de drogas para uso próprio (artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06)**.

Vejamos.

A **materialidade** do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelo laudo de constatação provisória (fls. 31/32), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 145/147), bem como pela prova oral coligida.

A **autoria**, de igual forma, é incontestada, devendo ser atribuída ao acusado.

Vejamos.

Na **fase inquisitiva**, ao ser **interrogado**, o **acusado** reservou-se no direito constitucional ao silêncio, asseverando que apenas se manifestaria perante a autoridade judiciária (fls. 06).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em juízo, interrogado sobre os fatos, o **acusado JOUBERT negou a prática da traficância**, asseverando que, na data dos fatos, ao ser abordado pelos policiais militares, realmente se encontrava na posse de oitenta e nove porções de cocaína, as quais serviriam para seu uso pessoal e em meio a uma “festa”, com alguns amigos. Ressaltou, pois, que recolheu o dinheiro entre seus amigos, ficando responsável pela aquisição do entorpecente, nesta cidade e comarca, posto que o valor era mais baixo do que em Ferraz de Vasconcelos. Salientou, pois, que oito pessoas se juntaram, de modo a dar R\$ 100,00, cada um, para a aquisição do entorpecente, recebendo, ainda, como brinde, nove porções do entorpecente, ressaltando que cerca de 24 pessoas fariam uso do entorpecente. Questionado, ainda, o acusado confirmou que já havia adquirido entorpecentes no local, inclusive *crack*. Confirmou, outrossim, antecedente criminal pela prática de violência doméstica, ainda sem trânsito em julgado. Ressaltou, ademais, já ter se internado em clínica para recuperação de viciados. Ao fim, outrossim, declarou-se arrependido do consumo de entorpecentes.

A testemunha **EDSON CORDEIRO VELOSO DE SOUZA**, policial militar, ouvido em juízo, declinou que, no dia dos fatos, se encontrava em patrulhamento de rotina, em conhecido ponto de tráfico de drogas, oportunidade em que avistou o acusado, em atitude suspeita, já que, portando uma sacola, passou a andar mais apressadamente ao avistar a viatura policial. Deste modo, deliberou pela abordagem do mesmo, porém o acusado partiu em fuga, sendo perseguido e detido. Em meio a busca pessoal, houve a localização, no interior da sacola por este carregada, de 80 a 90 porções de cocaína. Questionado, o acusado logo confessou a prática delituosa. Negou, veementemente, prévio conhecimento em relação ao acusado.

A testemunha **MAICON MARQUESANI MATIAS**, policial militar, ouvido em juízo, declinou que, no dia dos fatos, se encontrava em


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

patrulhamento de rotina, em conhecido ponto de tráfico de drogas, oportunidade em que avistou o acusado atravessando a rua, em atitude suspeita, já que, portando uma sacola de cor verde, passou a andar mais apressadamente ao avistar a viatura policial. Deste modo, deliberou pela abordagem do mesmo, porém o acusado partiu em fuga, sendo perseguido e detido. Em meio a busca pessoal, houve a localização, no interior da sacola por este carregada, de 89 porções de cocaína. Questionado, o acusado logo confessou a prática delituosa, salientando que revenderia o entorpecente no local em que residia. Negou, veementemente, prévio conhecimento em relação ao acusado. Questionado, ademais, o acusado confirmou ser usuário de entorpecentes, de modo que a venda da droga serviria para sustentar o próprio vício.

A testemunha **NELSON JOSÉ VIEIRA**, arrolado pela defesa e ouvida em juízo, declarou conhecer o acusado desde criança, de modo a destacar que o acusado fazia uso de substâncias entorpecentes. Salientou, outrossim, que o acusado já fez tratamento para se livrar do vício em entorpecentes, porém acabou por ter recaída, tanto é que, ultimamente, voltou a usar entorpecentes.

A testemunha **CINTIA APARECIDA PAIVA DA COSTA**, arrolado pela defesa e ouvida em juízo, declarou ser vizinha do acusado, o conhecendo há cerca de 29 anos. Confirmou, outrossim, se recordar de um período em que o acusado acabou por ser internado no estado do Paraná em uma clínica de recuperação. Negou, aliás, que o acusado seja traficante em sua residência. Destacou, sobre o entorpecente, que, segundo soube, o mesmo seria resultado de uma vaquinha para o consumo em uma festa.

Conforme se percebe dos **depoimentos suso transcritos**, a versão pelo acusado propalada no interrogatório judicial não é inverossímil, de modo que a mesma não restou afastada pela anêmica prova



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

produzida pela acusação, mormente pelo depoimento dos policiais militares, em juízo.

Ora, ponto comum ao depoimento dos dois policiais militares foi a assertiva de que os mesmos são responsáveis pelo patrulhamento de área, com íntimo contato com a comunidade (nas proximidades da Favela de Heliópolis), de modo que **NÃO CONHECIAM O ACUSADO DO LOCAL DOS FATOS**, o que demonstra que o mesmo **NÃO SERIA TRAFICANTE**.

Certo é, outrossim, que os próprios policiais militares asseveraram que **O ACUSADO É USUÁRIO DE ENTORPECENTES**.

Ademais, ainda se verifica que a quantidade de entorpecente apreendida com o acusado, embora pareça elevada, não o é após análise mais detida, posto que o **peso líquido total da droga foi de 67,1gramas**, o que significa que **cada invólucro continha MENOS DE UM GRAMA do entorpecente**.

Aliás, referido montante é perfeitamente compatível com o porte para uso próprio, conforme experiência em Varas Criminais, nesta comarca.

Destaque-se, pois, que NADA, absolutamente NADA, se produziu nos autos que pudesse ligar o acusado concretamente a qualquer atividade de mercancia e traficância no local (observe-se a ausência de apreensão de qualquer montante financeiro com o mesmo), de modo que a versão pelo mesmo propalada, de que adquiriria a droga para seu consumo e com outros amigos, em meio a uma festa, há de ser acolhida.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ora, tais fatos, assim, levam, inexoravelmente, à **DESCCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ATRIBUÍDA**, para o **delito de porte de drogas para uso próprio**, conforme até mesmo confessado pelo acusado, nesta data, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, reconhecidas autoria e materialidade do **crime de porte para uso próprio (artigo 28 da Lei nº 11.343/06)** imputado ao acusado, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena, salientando, aliás, que o **acusado não faz jus à transação penal** por conta de condenação criminal anterior (**artigo 76 da lei nº 9.099/95**).

Nos termos do **artigo 28 da Lei nº 11.343/06**, entendo que, ante a quantidade e tipo de droga apreendida, deva o acusado ser submetido à **pena de advertência sobre os efeitos das drogas**.

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para o fim de **ABSOLVER**, com fulcro no **artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal**, o acusado **JOUBERT SANTOS MACHADO**, qualificado nos autos, da imputação que lhe é dirigida na denúncia, por incursão nas penas do **artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**, e **DECLARÁ-LO COMO INCURSO** nas penas do **artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06**. Em consequência, **condeno-o à pena de advertência sobre os efeitos das drogas**.

Esta sentença, proferida nesta data, servirá, desde já, como a advertência determinada, sem maiores formalidades.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea

0007774-29.2017.8.26.0635 - lauda 9



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“a”, da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno a acusada ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, sendo que, ante a **hipossuficiência demonstrada, suspendo a exigibilidade de referido pagamento, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil Brasileiro.**

Expeçam-se as comunicações de praxe.

Ao transito em julgado, arquivem-se os autos.

Oficie-se autorizando a incineração da substância entorpecente apreendida nos autos.

Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Registre-se e Cumpra-se.

São Paulo, 14 de novembro de 2017.

RAFAEL HENRIQUE JANELA TAMAI ROCHA

Juiz de Direito

(assinado digitalmente)

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**